

1512414-64.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512414-64.2021.8.26.0019 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512414-64.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2207406/2021 - 02º D.P. AMERICANA, 19369946 - 02º D.P. AMERICANA, 1122/21/345 - 02º D.P. AMERICANA, 2207406 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 1122/21/345 - DISE- DEL.SEC.AMERICANA, 2207406/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Americana

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO TADEU RIGHI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

RICARDO TADEU RIGHI está sendo processado como incurso nas sanções dos artigos 33, 'caput' da Lei 11.343/06, acusado de no dia 02 de agosto de 2021, por volta de 18 horas, na Rua Serra das Araras, 65, Bairro Parque da Liberdade, nesta cidade, guardar e manter em depósito, para fins de tráfico, 47 pedras de crack, droga derivada da cocaína, com peso de 2,2 gramas, 08 porções de cocaína, com peso total de 8,4 gramas e 16 porções de maconha, com peso de 19,3 gramas, embaladas separadamente, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros, substâncias essas que provocam dependência física e psíquica, assim o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Recebida a denúncia em 18 de abril de 2022 (fls. 112/113), o réu foi citado (fls. 132).

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa (fls. 97) e a acusação (fls. 110/111).

Na instrução foram inquiridas duas testemunhas comuns e uma testemunha de Defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, alegando provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime.

A Defesa, em memoriais, reclamou de nulidade porque houve violação de domicílio, sem mandado ou autorização. Não foram realizadas diligências prévias que indicassem a existência de entorpecentes no imóvel. O transeunte que teria informado a prática do tráfico de drogas, nada mencionou em relação à casa do réu. Ninguém autorizou a entrada dos policiais no imóvel, que invadiram a residência pelo simples fato do acusado não portar documentos. Cita doutrina e jurisprudência. As provas seriam insuficientes. A dúvida deveria vir em benefício do réu. Durante a abordagem foi localizada uma única pedra de crack com o acusado, que não era investigado. Não foram apreendidos valores em espécie ou qualquer outro objeto relacionado à prática do crime de tráfico de drogas. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

Para o caso de condenação, pretende redução da pena porque primário (artigo 33, par. 4º), alertando ser confesso, atenuante. Pena mínima, com regime brando. Faria jus a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. Por fim, pugnou pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls. 150/159). É o relatório.

DECIDO.

A preliminar não procede.

Pelo que se depreende dos autos, o réu admitiu que estava em situação que exigia intervenção dos agentes da autoridade, a qual, ocorrida e com revista, resultou na apreensão de droga, ocultada na boca.

Havia indicativo de ocorrência de crime, que é permanente (tráfico) e a inviolabilidade do domicílio, para a realização da prisão em flagrante (não para a busca, como é a hipótese) assim, sofre atenuação pelo interesse coletivo em se apurar, prevenir e punir a prática de crime.

A ida à casa do réu, pois, não foi gratuita ou ocasional, mas movida por policiamento preventivo. O réu teria admitido para os militares que usava entorpecentes e estava sem documentos. Indicou o endereço da sua casa, local em que a equipe foi recepcionada pela sua avó, que permitiu que olhassem o imóvel e acompanhou as diligências (fls. 04), positiva para o encontro de drogas, situação de crime.

Inclusive, a respeito, já definiu o C. STF, pelo Plenário, no R.E. 603616:

"A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No E. TJDF:

"1. Não caracteriza violação de domicílio o ingresso em residência, ainda que não autorizado, a qualquer hora do dia e da noite, para efetuar prisão em flagrante de crime permanente sobre o qual pairam indicativos seguros de sua prática." Acórdão 1290791, 07443800320208070000, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 18/10/2020.

No mérito, a denúncia é procedente.

O réu foi preso em flagrante e preservou silêncio (fls. 04).

"Na real verdade, preso naquelas circunstâncias a que a tradição do direito chama 'certeza visual do crime' (cf. Tostes Malta, Do flagrante delito, 1933, p. 25), e permanecendo calado na Polícia (fl.7), em vez de repelir, com a última força, a imputação, como fazem os inocentes, apenas o decreto condenatório poderia atender a um tempo à prova dos autos, à razão lógica e aos ditames da Justiça. Cai a lança aquilo de Peter Thorton: 'A inocência pelo direito de falar; a culpa, essa invoca o privilégio do silêncio' (Justice on trial, p. 36; Revista da Escola Paulista da

Magistratura, 2, p. 117). Impossível dizer melhor!" (TACRIM SP, 15ª C. - AP 1.286.483/3 - Rel. Carlos Biasotti, j. 07.02.2002, rolo-flash 1472/110).

"Embora a opção pelo silêncio derive de previsão constitucional, ela não inviabiliza o convencimento judicial no sentido desfavorável ao réu, pois a reação normal do inocente é proclamar, com insistência e ênfase, a sua inocência não se reservar para prestar esclarecimentos apenas em Juízo." (Ap. Crim. 1070141/5, Taubaté, Rel. Renato Nalini, TACRIM SP, j. em 20.10.1997).

"PROVA. Interrogatório policial. Silêncio do réu. Valor. O silêncio do réu, quando interrogado na fase policial, direito constitucional que lhe foi assegurado, é comprometedor, pois o inocente brada desde logo sua inocência e apresenta eventual alibi ou justificativa de seu ato." (TACRIM SP, AC 1.288.149/1, SP, 8ª Câmara, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 13.12.2001).

Já no interrogatório judicial, alegou que subia a Praça da Fraternidade, estava sem documentos. Foi abordado pelos policiais, que encontraram a pedra de crack em seu poder. Os militares não disseram que entrariam na sua casa. Não autorizou a entrada dos policiais em sua casa, nem a sua avó. Apenas disse que poderiam ir buscar o seu documento, para que pedissem para a sua avó trazer. Os policiais chegaram e já entraram no imóvel.

Estava na viatura, não pôde ver as buscas. Confirmava que foram encontradas drogas em sua casa.

A versão não convence.

O Policial Militar Leonardo Regis Gonçalves Batista esclareceu que patrulhavam pelo bairro Jardim da Paz, quando foram solicitados por um homem. O denunciante relatou que um rapaz saía da casa dele e se deslocava até a Praça da Fraternidade, para cometer o crime de tráfico de drogas. Detalhou que os fatos eram recorrentes, com descrição das características do suspeito. Realizaram patrulhamento e lograram êxito em localizar o réu, que foi abordado. Revistou o Ricardo, localizou uma porção de droga, que estava dentro da sua boca. Durante a entrevista, questionaram se havia mais entorpecentes na sua casa e ele negou. No entanto, pediram para irem até o imóvel, pois o réu estava sem documentos. Deslocaram-se até a residência do acusado e foram recepcionados pela avó dele, que declarou ser moradora da residência. Ambos franquearam a entrada da equipe. Como a casa era muito fechada, solicitaram o apoio do canil. A Guarda Municipal trouxe animais treinados, que encontraram mais drogas, escondidas no telhado da residência. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao acusado, que foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária. Após a confirmação da localização da droga, posteriormente Ricardo admitiu que estava traficando, para conseguir pagar uma dívida que ele possuía. O denunciante era um senhor moreno, morador do bairro.

Evellyn Laize do Prado, outra Policial, ratificando a versão do colega, lembrou-se de que a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Parque da Liberdade, quando foram solicitados por um popular, que fez uma acusação de tráfico. O denunciante descreveu que um homem de pele morena, de estatura mediana, com tatuagens no braço e no pescoço, realizava o tráfico de drogas pela Praça da Fraternidade.

Intensificaram o patrulhamento na Rua Serra Formosa, ocasião em que avistaram um homem, com as mesmas características descritas na denúncia. Realizaram a abordagem e o revistaram, localizando uma porção de crack, dentro da boca do réu. Indagado, ele negou a traficância. Solicitaram para irem até a residência do acusado, situada nas proximidades do local, para realização de buscas e foi autorizado. A avó do Ricardo permitiu a entrada da equipe no imóvel.

Acionaram o apoio do canil e a cadela 'Hana' encontrou uma sacola plástica, entre os vãos do telhado, com maconha, cocaína e crack. Ao ser questionado sobre o material localizado, o réu finalmente confessou que estava na prática de tráfico de drogas, para pagar uma dívida. Deram voz de prisão para o Ricardo, que foi conduzido até plantão policial, para deliberações da autoridade competente. O denunciante aparentava ter aproximadamente cinquenta anos, era um homem moreno, que preferiu não se identificar, com medo de sofrer represálias. Foram até a residência do acusado em razão dele não portar documentos e pelo fato de terem encontrado uma pedra de crack na boca do abordado. A busca domiciliar foi realizada mediante a autorização do proprietário.

A testemunha de Defesa Maria Aparecida Alves, avó do acusado, explicou que os policiais chegaram na sua casa e o encostaram no muro. Ficou assustada e foi questionar o ocorrido, obteve como resposta que era em razão do seu neto não portar documentos, que vieram buscá-los. Enquanto conversava com alguns dos policiais, outros policiais foram até os fundos, local em que o Ricardo morava. Viu policiais em cima do telhado, que alegaram que o réu tinha drogas escondidas. Permitiu as buscas, quando viu, vários policiais já estavam dentro da casa. Acreditava que o seu neto não tinha nada de ilícito. Avisou os policiais que tinha feito o telhado por aqueles dias, pediu cuidado para que não quebrassem as suas telhas novas. Passou mal quando os policiais acharam os entorpecentes. Não assinou nenhuma autorização para os policiais. Tinha deixado eles entrarem, pois desconhecia sobre a existência qualquer ilícito.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

Como já obtemperado, transeunte, inconformado com o tráfico ocorrido em plena praça do bairro, alertou os policiais a respeito do crime e do suspeito, que descreveu. Patrulhando, os policiais avistaram ao réu, que correspondia às características e abordado, levava na boca uma porção de droga, tal qual denúncia, de que se movia constantemente o traficante pelo local, com trazida e venda de drogas amiúde. Sem documentos, os policiais foram até a casa do réu, avisaram a avó a respeito da presença no local e a busca foi autorizada. Em local não usual, telhado, encontraram drogas em quantidade e forma de acondicionamento que não indicava destinação outra senão o tráfico (39 (trinta e nove) pinos de "cocaína", 16 (dezesesseis) porções de "maconha", 8 (oito) porções petrificadas de "cocaína" e mais 8 (oito) pedras de "crack"). Aliás, tal foi confessado pelo réu aos policiais, com a justificativa de que teria dívida a pagar. A avó do réu também admitiu que no telhado foi encontrado droga, surpreendendo-a.

Bem certa, a prova, assim, quanto a efetiva ocorrência do tráfico. As circunstâncias da prisão, após denúncia de popular; a apreensão das drogas, já embaladas em pequenas porções, prontas para a venda e entrega ao consumo de terceiros; evidenciam que ele vinha se dedicando a essa atividade criminosa. A quantidade e disposição, não permite inferir conclusão outra senão a de que se destinassem ao tráfico.

A prova, pois, é segura e convincente quanto a responsabilidade criminal do acusado.

A alegação de que a droga seria para uso próprio, não foi provada e muito menos é crível, pela citada forma em que estavam embaladas e quantidade, local onde o réu as mantinha, ocultas no telhado da casa.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o álibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao incriminado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7^a ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O álibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

Também:

"Quem invoca um álibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (TJSP, AP. 53.726, Rel. Azevedo Franceschini).

A conduta é mesmo a de tráfico, não sendo necessário, para a hipótese, que o réu estivesse vendendo drogas. A acusação é pontual em alegar que ele guardava e mantinha em depósito, drogas, para a mercancia.

Trata-se de crime de ação múltipla e conteúdo variado, não carecendo a prática de atos de mercancia para a configuração do tráfico.

Confira-se: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual

28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347).

"ENTORPECENTE - Tráfico - Agente que não comercializou a droga - Caracterização pela simples guarda, pois o tipo do art. 12 da Lei 6.368/76 é de conteúdo variado ou misto alternativo" (TJRS, RT 745/633).

E, por pertinente: "ENTORPECENTE - Tráfico - Caracterização - Crime de perigo abstrato - Desnecessidade da prática de efetivo ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito a substância entorpecente, para finalidade de venda. Inteligência do art. 12, caput, da Lei 6.368/76" (TJSP, RT 793/576).

Também o fato de ser usuário de drogas, repete-se, não afasta a traficância, quando o porte de eventual droga é absorvido pelo crime de maior severidade, no caso, o tráfico.

A prova, enfim, é boa e suficiente, com prisão em flagrante delito, certeza visual do delito, apreensão da droga e depoimentos de policiais.

A versão dos policiais militares, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

É do C. STF: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

A alegação de necessidade, em sua versão, de todo o modo não lhe dá direito ou permissão para trazer com ele drogas, para o grave crime de tráfico, mormente quando alega que tinha dívida e a mercancia seria necessária para obter dinheiro. Incabível o reconhecimento de inexigibilidade de conduta porque não comprovado que o meio escolhido era o único disponível diante da situação.

Nesse sentido:

Apelação. Tráfico. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Acusação pugna pelo afastamento da redutora do §4 do art. 33. Privilégio mantido, com fração reduzida. Réu primário e portador de bons antecedentes. Regime inicial alterado para o semiaberto. Grande quantidade e variedade de drogas. Tese de inexigibilidade de conduta diversa não acolhida. Não comprovação de que, de fato, o meio escolhido era o único disponível diante da situação. Confissão que já foi reconhecida, mas sem reflexo na pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não permitida. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso defensivo não provido (TJSP; Apelação Criminal 1503966-14.2018.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal; J. em 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020).

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo laudo de constatação (fls. 10/13) e pelo exame químico toxicológico (fls. 66/68).

Por isso de rigor a condenação.

Fixação das penas.

O réu é primário. Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias a serem consideradas. Mantenho inalterada a pena base.

Na terceira fase, pela primariedade e não comprovação de que integrasse associação ou organização criminosa, possível a redução de pena no percentual de metade, o que se faz em atenção à quantidade-nocividade de droga apreendida.

Possível a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos, reconhecido o tráfico privilegiado e a somatória final da pena, com estipulação do regime aberto para o caso de revogação.

Ressalvado entendimento pessoal a respeito da gravidade da conduta, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o disposto no artigo 33, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal.

Depois, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o entendimento de que: "Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as particularidades do caso concreto." HC nº 239.999/MS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 21.08.2014.

Na mesma evolução, com a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (popularmente conhecida como "pacote anticrime"), houve necessidade de maior reflexão pelos julgadores. Dentre as alterações previstas no regime legal, houve alteração expressa da Lei de Execuções Penais, em especial no tocante ao "tráfico privilegiado": Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...) § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

É de se impor o regime inicial aberto, pela somatória da pena, reclusiva, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em decorrência da primariedade e as circunstâncias judiciais já destacadas.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar RICARDO TADEU RIGHI às penas de dois (02) anos e seis (06) meses de reclusão, regime inicial aberto e duzentos e cinquenta (250) dias-multa, piso, por infração ao artigo 33, 'caput' e § 4º, ambos da Lei 11.343/2006.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena e mais dez (10) dias-multa, piso.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Iento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 40).

Vinculado o numerário apreendido e objetos com o crime cometido, decreto a sua perda em favor da União, ficando autorizado, quanto a estes últimos, doação ou destruição, acaso inservíveis ou sem valor econômico, o que será certificado, se o caso.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome da ré no rol dos culpados.

Faculto recurso em liberdade, porque assim o réu vem respondendo aos atos do processo, mantidas eventuais medidas cautelares acaso impostas quando da concessão de benesse processual, até transito em julgado.

P.I.C.

Americana, 11 de outubro de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA